

EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM nº RJ2015/12856

Acusado: Pedro Demenato Fernandes.

Ementa: Não realização obrigatória de Oferta Pública de Aquisição de Ações por alienação de controle. Multa.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, com fundamento no art. 11 da Lei nº 6.385/76, decidiu:

1. APLICAR ao acusado **Pedro Demenato Fernandes a penalidade de multa pecuniária no valor de R\$400.000,00**, por não ter realizado Oferta Pública de Aquisição de Ações quando da aquisição do controle acionário da companhia Marambaia Energia Renovável S.A., descumprindo, dessa forma, o disposto nos artigos 254-A da Lei nº 6.404/76 e 29 da Instrução CVM nº 361/02.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM nº 538/2008.

Ausente o acusado e o seu representante constituído.

Presente a Procuradora-federal Cristiane Iwakura, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Henrique Balduino Machado Moreira, Relator, Gustavo Borba, Gustavo Gonzalez, Pablo Renteria e o Presidente da CVM, Marcelo Santos Barbosa.

Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2017.

Henrique Balduino Machado Moreira
Diretor-Relator

Marcelo Santos Barbosa
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2015/12856

Acusado: Pedro Demenato Fernandes

Assunto: Apurar a eventual responsabilidade pela não realização de oferta pública de aquisição de ações por alienação de controle, em infração ao disposto nos artigos 254-A, da Lei nº 6.404/76, e 29, da Instrução CVM nº 361/02, em

decorrência da aquisição do controle acionário da Marambaia Energia Renovável S.A.

Relator: Diretor Henrique Balduino Machado Moreira

RELATÓRIO

I – Do Objeto.

1. Trata-se de Termo de Acusação elaborado pela Superintendência de Registro de Valores Mobiliários em 07.12.2015¹ (“SRE” ou “Acusação”), em face de Pedro Demenato Fernandes (“Pedro Demenato”, ou “Acusado”), para apurar a eventual responsabilidade pelo descumprimento do art. 254-A² da Lei nº 6.404/76 e do art. 29³ da Instrução CVM nº 361/02, por não ter realizado oferta pública de aquisição de ações (“OPA”) obrigatória, em decorrência da aquisição do controle acionário da Marambaia Energia Renovável S.A. (“Marambaia Energia”, ou “Companhia”).

II – Dos Fatos.

2. A Gerência de Acompanhamento de Empresas 4 (“GEA-4”) verificou que nas Informações Anuais (IAN) da Companhia referentes a junho de 2009 (fls. 25-26) constava que o controle acionário da Companhia era exercido pelas sociedades Marambaia Capital S.A. (“Marambaia Capital”), com participação de 49,85%, e Marambaia Investimentos e Participações Ltda. (“Marambaia Investimentos”), detentora de ações representativas de 50,15%⁴ do capital social, e que no Formulário de Referência de 2010⁵ constava que Pedro Demenato era controlador, com participação equivalente a 50,41% das ações ordinárias de emissão da Companhia (fls. 27-32).

3. Tal informação coincidia com a constante da lista de acionistas da Marambaia Energia enviada pelo Itaú Unibanco S.A. (“Itaú”) (data-base 07.03.2012), em que constava Pedro Demenato como detentor de 6.544.116 ações, representativas de 50,41% do capital social da Companhia (fls. 7-23)⁶.

4. Assim, no dia 14.03.2013, foi enviado ofício⁷ à Companhia, informando que não havia sido identificada uma divulgação acerca da mudança do controle, e solicitando que a Marambaia Energia informasse como e quando teria ocorrido a alienação do controle e o quadro acionário antes e depois da operação, com a identificação dos acionistas detentores de mais de 5% das ações de emissão da Companhia.

5. Em resposta protocolada em 26.03.2013 (fls. 33), a Companhia informou que Pedro Demenato constava no Formulário de Referência como controlador *“haja vista o mesmo em 19 de Outubro de 2009 por meio de OTA [Ordem de Transferência de Ações] adquiriu as referidas ações (sic)”* e ressaltou que nenhum outro acionista teria atingido o percentual de 5%⁸.

6. O assunto foi encaminhado à SRE, que, no dia 17.07.2015, intimou Pedro Demenato a manifestar-se acerca da alienação das ações da Companhia sem a realização de oferta pública de aquisição das ações com direito a voto de propriedade dos demais acionistas⁹.

7. Como não foi apresentada resposta, a SRE enviou novo ofício¹⁰, por meio do qual reiterou os termos da primeira intimação e informou que o não atendimento acarretaria a incidência de multa diária de R\$ 1.000,00, nos termos do §11 do art. 11 da Lei nº 6.385/76. Em razão da ausência de resposta, foi aplicada uma multa cominatória de R\$ 10.000,00¹¹.

8. Em 22.10.2015, foi enviado o OFÍCIO/CVM/SRE/nº 712-2015 ao Itaú (fls. 43), prestador de serviços escriturais da Companhia até 06.03.2012, solicitando o envio de cópia da documentação que embasou a transferência de ações para o Acusado. Em resposta, foi encaminhado o formulário de transferência de 4.108.562 ações ordinárias da Companhia, realizada no dia 19.10.2009 (fls. 44-46), constando, como cedente, a Marambaia Investimentos, e, como cessionário, Pedro Demenato. O documento indica ainda que as ações teriam sido adquiridas pelo valor unitário de R\$1,00, totalizando R\$4.108.562,00.

9. Segundo a SRE¹², *"o preço unitário praticado na aquisição realizada pelo Sr. Pedro Demenato Fernandes em 19.10.2009 correspondia à cerca de 47% (quarenta e sete por cento) do preço médio de negociação das ações da Marambaia Energia na Bovespa, na época, pois, segundo o Boletim Diário da Bolsa (fl. 47), o preço médio das ações, naquela data, foi de R\$ 2,14 (dois reais e quatorze centavos)."*

10. Foram enviados ainda outros ofícios¹³ ao Acusado que, apesar de devidamente intimado, permaneceu inerte.

11. É importante ressaltar que, no dia 07.01.2013, a Marambaia Energia teve o seu registro de emissor cancelado pelo Superintendente de Relações com Empresas (fls. 63), com base no inciso II do art. 54 da Instrução CVM nº 480/09, por ter ficado com o seu registro suspenso por período superior a 12 meses (fls. 62).

III – Da Acusação.

12. Com base nas informações coletadas, concluiu a SRE que teria havido a alienação do controle da Marambaia Energia para o Acusado, sem que este tenha formulado pedido de registro de OPA nesta Autarquia, em infração ao disposto nos artigos 254-A da Lei nº 6.404/76 e 29 da Instrução CVM nº 361/02, sendo a infração a este último considerada grave, nos termos do art. 36 da mesma Instrução.

13. Com relação ao efetivo exercício do poder de controle, afirmou a Acusação que:

30. A fim de comprovar o efetivo exercício, antes de 19.10.2009, do poder de controle da Marambaia Capital e da Marambaia Investimentos, nos termos do art. 116 da Lei nº 6.404/76, observa-se que tais sociedades eram as únicas acionistas presentes na Assembleia Geral Extraordinária – AGE de 12.12.2007 (fls. 70) e detinham mais de dois terços do capital social da companhia.

31 Na Assembleia Geral anterior da Marambaia Energia, realizada em 30.04.2007 (fls. 71 a 86), a Marambaia Capital e a Marambaia Investimentos também estiveram presentes. Nela, ocorreu a eleição do Sr. L.C.F. para o Conselho de Administração da referida companhia. Na procuração utilizada pela Sra. S.P.N. para representar a Marambaia Capital e a Marambaia Investimentos nesta Assembleia Geral (fl. 87), consta que os outorgantes foram representados pelo Diretor-Presidente das referidas empresas, que era o mesmo Sr. L.C.F.

14. Diante do posicionamento omissivo do Acusado e em posse dos fatos apurados, a SRE apresentou Termo de Acusação, em que pede a responsabilização pela alienação do controle da Marambaia Energia sem a realização da devida oferta pública de aquisição de ações, em violação aos artigos 254-A da Lei nº 6.404/76 e 29 da Instrução CVM nº 361/02 (fls. 92-105).

IV – Da Manifestação da Procuradoria (fls. 106-107).

15. Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (PFE-CVM) entendeu estarem preenchidos os requisitos constantes dos artigos 6º e 11¹⁴ da Deliberação CVM nº 538/08, por meio do Parecer nº 00119/2015/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU de 04.01.2016.

V – Da Defesa.

16. Apesar de regularmente intimado¹⁵, Pedro Demenato Fernandes não apresentou suas razões de defesa.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2017.

Henrique Balduino Machado Moreira
Diretor-Relator

¹ Fls. 92-104.

² Art. 254-A – A alienação, direta ou indireta, do controle de companhia aberta, somente poderá ser contratada sob a condição, suspensiva ou resolutiva, de que o adquirente se obrigue a fazer oferta pública de aquisição das ações com direito a voto de propriedade dos demais acionistas da companhia, de modo a lhes assegurar o preço no mínimo igual a 80% (oitenta por cento) do valor pago por ação com direito a voto, integrante do bloco de controle.

³ Art. 29 – A OPA por alienação do controle de companhia aberta será obrigatória, na forma do art. 254-A da Lei 6.404/76, sempre que houver alienação, de forma direta ou indireta, do controle de companhia aberta, e terá por objeto todas as ações de emissão da companhia às quais seja atribuído o pleno e permanente direito de voto, por disposição legal ou estatutária.

⁴ As sociedades Marambaia Capital S.A. (CNPJ nº 03.001.238/0001-20) e Marambaia Investimentos e Participações Ltda. (CNPJ nº 40.252.710/0001-23) detinham, à época, 6.163.215.718 e 6.199.704.748 ações ordinárias, respectivamente, e juntas detinham participações equivalentes a 100% do capital social.

⁵ De acordo com a SRE, “no Formulário de Referência de 2010, encaminhado em 01.11.2010 (fl. 27 a 32), consta no item 8.1 a informação de que ‘atualmente, consta como controlador o senhor Pedro Demenato Fernandes, e as demais ações divididas entre acionistas minoritários’. No item 8.2 do Formulário consta o organograma da companhia e a informação de que o Sr. Pedro Demenato Fernandes é seu controlador, com 50,41% das ações. Nos itens 15.1 e 15.2 foi informado que o Sr. Pedro Demenato Fernandes (CPF 101.404.017-50) detinha 50,41% das ações ordinárias da companhia. No entanto, nos itens 15.6 e 15.7 do Formulário, que tratam de alteração relevante de participação (controle e administração) e de outras informações relevantes (controle), não foi informada a mudança no controle da companhia” (item 25 do termo de acusação).

⁶ Consta na referida lista que a Companhia possuía 12.981.001 ações, sendo 6.544.116 de propriedade de Pedro Demenato e 6.436.885 ações detidas pelos minoritários.

⁷ OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-4/Nº 070/13, de 14.03.2013 (fls. 24).

⁸ De acordo com o termo de acusação, a informação fornecida pela Companhia “(...) está em linha com a resposta da Marambaia Investimentos (que aparecia como uma das controladoras da Marambaia Energia no IAN de 2009) ao OFÍCIO/CVM/GMA-1/Nº 52/11, de 18.07.2011 (fls. 34 e 35), que solicitou informações sobre os negócios realizados com ações da Marambaia Energia no período de junho/2009 a novembro/2010. Na resposta, datada de 19.08.2011 (fl. 36), a Marambaia Investimentos informou que cedeu 4.108.562 (quatro milhões, cento e oito mil, quinhentas e sessenta e duas) ações em 19.10.2009, mas, “por razões de reestruturação de espaço físico, a mesma acabou por não informar”. Entretanto, a Marambaia Investimentos não informou para quem as ações foram transferidas” (item 10 do documento).

⁹ OFÍCIO Nº 479/2015/CVM/SRE, de 17.07.2015 (fls. 37-39).

¹⁰ OFÍCIO Nº 549/2015/CVM/SRE, de 14.08.2015 (fls. 40-41).

¹¹ A multa foi comunicada por meio do OFÍCIO/CVM/SRE/Nº 604/15, de 15.09.2015 (fls. 42).

¹² Item 16 do termo de acusação (fls. 94-95).

¹³ OFÍCIO Nº 713/2015/CVM/SRE, de 26.10.2015 (fls. 48-50) e OFÍCIO Nº 745/2015/CVM/SRE de 05.11.2015 (fls. 67-69).

¹⁴ Art. 6º - Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7º, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão constar: I - nome e qualificação dos acusados; II - narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das infrações apuradas; III - análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas; IV - os dispositivos legais ou regulamentares infringidos; e V - proposta de comunicação a que se refere o art. 10, se for o caso.

Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório, ou no termo de acusação, conforme o caso. Parágrafo único. Considerar-se-á atendido o disposto no *caput* sempre que o acusado: I - tenha prestado depoimento pessoal, ou se manifestado voluntariamente acerca dos atos a ele imputados; ou II - tenha sido intimado para prestar esclarecimentos sobre os atos a ele imputados, ainda que não o faça.

¹⁵ O Acusado foi intimado por meio de correspondência com A.R. (fls. 112-117) e por edital (fls. 118-121).

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2015/12856

Acusado: Pedro Demenato Fernandes

Assunto: Apurar a eventual responsabilidade pela não realização de oferta pública de aquisição de ações por alienação de controle, em infração ao disposto nos artigos 254-A, da Lei nº 6.404/76, e 29, da Instrução CVM nº 361/02, em decorrência da aquisição do controle acionário da Marambaia Energia Renovável S.A.

Relator: Diretor Henrique Balduino Machado Moreira

VOTO

1. Trata-se de Termo de Acusação elaborado pela Superintendência de Registro de Valores Mobiliários em 07.12.2015 ("SRE", ou "Acusação"), em face de Pedro Demenato Fernandes ("Pedro Demenato", ou "Acusado"), para apurar a eventual responsabilidade pelo descumprimento dos artigos 254-A¹, da Lei nº 6.404/76, e 29², da Instrução CVM nº 361/02, por não ter realizado uma Oferta Pública de Aquisição de Ações ("OPA") obrigatória, em decorrência da aquisição do controle acionário da Marambaia Energia Renovável S.A. ("Marambaia Energia", ou "Companhia").

2. Afirma a Acusação que, no dia 19.10.2009, o controle da Marambaia Energia teria sido alienado a Pedro Demenato, sem que este tenha formulado pedido de registro de OPA nesta Autarquia, o que teria caracterizado infração ao disposto no art. 254-A da Lei nº 6.404/76, bem como ao disposto no art. 29 da Instrução CVM nº 361/02.

3. Alega que, anteriormente à operação, o controle da Companhia era exercido pela Marambaia Capital e pela Marambaia Investimentos, que detinham 49,85% e 50,15% do Capital social³, respectivamente, e, ainda, eram as únicas acionistas presentes na última AGE realizada antes da operação, com Pedro Demenato⁴. Na assembleia anterior, realizada em 30.04.2007 (fls. 71-86), a Marambaia Capital e a Marambaia Investimentos

também estiveram presentes, ocasião em que L.C.F. foi eleito para o Conselho de Administração da referida Companhia⁵.

4. Portanto, aduz a Acusação que, após a transferência das ações da Marambaia Energia, Pedro Demenato passou a controlar a Companhia, pois lhe teria sido assegurado, de modo permanente, a maioria dos votos nas deliberações da assembleia geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia, tendo sido o Acusado eleito diretor vice-presidente e de relações com investidores, em reunião do Conselho de Administração da Marambaia Energia realizada em 04.10.2010⁶.

5. O Acusado não respondeu a nenhum dos ofícios enviados pela SRE na fase investigatória e tampouco apresentou defesa, após ter sido devidamente intimado para tal.

6. Neste ponto, antes de adentrar no mérito, importa traçar um brevíssimo histórico acerca do direito de venda conjunta (ou *tag along*) dos acionistas minoritários no direito pátrio. Introduzida no ordenamento jurídico com a promulgação da Lei nº 6.404/76, a redação original do art. 254 previa o direito de saída conjunta aos minoritários pelo mesmo preço pago ao alienante das ações que lhe asseguravam o poder de controle. Estabelecia, ainda, que a alienação do controle da companhia aberta dependeria de prévia autorização da CVM, que deveria *"zelar para que seja assegurado tratamento igualitário aos acionistas minoritários, mediante simultânea oferta pública para aquisição de ações"*⁷.

7. Anos depois, o art. 6º da Lei nº 9.457/97 revogou expressamente o art. 254 e os parágrafos do art. 255 que previam a aplicação do *tag along* às companhias com controle estatal, tendo como justificativa adaptar a lei à *"nova realidade da economia brasileira à época e "incentivar o desenvolvimento do mercado de capitais no Brasil(...)"*⁸

8. Especificamente com relação à exclusão do *tag along*, a justificativa do projeto defendia que *"apenas na aparência esse dispositivo favorece o acionista minoritário. Na prática, por inibir processos de saneamento e capitalização em que a alienação do controle é indispensável, o dispositivo contribui para inviabilizar definitivamente empresas em dificuldade e, assim, gerar prejuízos que recaem sobretudo sobre os minoritários"*.

9. A par de tal justificativa, sobreveio um forte movimento para que os direitos econômicos dos minoritários fossem fortalecidos, o que ocorreu com a grande reforma introduzida pela Lei nº 10.303/01. Assim, foi reincorporado à Lei nº 6.404/76, por meio do art. 254-A (abaixo transcrito), o direito de venda conjunta pelos minoritários em caso de transferência de controle, com algumas alterações em relação à redação original, como o pagamento de 80% do valor pago aos alienantes detentores do controle (o texto anterior estabelecia igual valor) e a definição expressa dos destinatários da oferta.

Art. 254-A. A alienação, direta ou indireta, do controle de companhia aberta, somente poderá ser contratada sob a condição, suspensiva, ou resolutiva, de que o adquirente se obrigue a fazer oferta pública de aquisição das ações com direito a voto de propriedade dos demais acionistas da companhia, de modo a lhes assegurar o preço no mínimo igual a 80% (oitenta por cento) do valor pago com ação com direito a voto, integrante do bloco de controle.

§1º - Entende-se como alienação de controle a transferência, de forma direta, ou indireta, de ações integrantes do bloco de controle, de ações vinculadas a acordos de acionistas e de valores mobiliários conversíveis em ações com direito a voto,

cessão de direitos de subscrição de ações e de outros títulos ou direitos relativos a valores mobiliários conversíveis em ações que venham a resultar na alienação de controle acionário da sociedade.

§2º - A Comissão de Valores Mobiliários autorizará a alienação de controle de que trata o caput, desde que verificado que as condições da oferta pública atendem aos requisitos legais.

§3º - Compete à Comissão de Valores Mobiliários estabelecer normas a serem observadas na oferta pública de que trata o caput.

§4º - O adquirente do controle acionário de companhia aberta poderá oferecer aos acionistas minoritários a opção de permanecer na companhia, mediante o pagamento de um prêmio equivalente à diferença entre o valor de mercado das ações e o valor pago por ação integrante do bloco de controle.

10. Ressalta-se que, apesar de o novo texto legal ter atribuído um valor diferenciado às ações integrantes do bloco de controle, diferença denominada por alguns doutrinadores⁸ “*ágio*”, ou “*prêmio de controle*”, a alteração legislativa veio a restabelecer direito de significativa importância para proteção dos acionistas minoritários e, em última análise, para o próprio desenvolvimento do mercado de capitais⁹.

11. Trata-se de uma “*socialização parcial do prêmio de controle*”¹⁰, que “exige do potencial adquirente um investimento que engloba, além do preço de compra das ações do bloco de controle, montante necessário para adquirir as ações dos minoritários que optarem por aceitar a oferta. Em geral, implica redução do valor global que seria pago ao controlador alienante pelo adquirente, caso este não tivesse que lançar a oferta de compra aos minoritários”¹¹⁻¹².”

11. Na mesma linha, o Colegiado da CVM já se manifestou ao afirmar que a finalidade do art. 254-A seria “*conferir a possibilidade de uma “compensação” à quebra da estabilidade do quadro acionário, permitindo que os acionistas minoritários alienem as suas ações por preço determinado em lei (que pode ser aumentado pelo estatuto social), quando essa estabilidade for perturbada*”¹³”.

12. Com a reintrodução do direito de venda conjunta em 2002, a CVM editou a Instrução CVM nº 361, que veio disciplinar o procedimento aplicável às ofertas públicas de aquisição de ações de companhia aberta, sendo a oferta pública por alienação de controle tratada nos artigos 29 e 30. No art. 29 estão previstos os principais requisitos e elementos da obrigação, transcritos a seguir:

Art. 29. A OPA por alienação de controle de companhia aberta será obrigatória, na forma do art. 254-A da Lei 6.404/76, sempre que houver alienação, de forma direta, ou indireta, do controle de companhia aberta, e terá por objeto todas as ações de emissão da companhia às quais seja atribuído o pleno e permanente direito de voto, por disposição legal, ou estatutária.

§1º - A OPA deverá ser formulada pelo adquirente do controle, e o seu instrumento conterá, além dos requisitos estabelecidos pelo art. 10, as informações contidas na notícia de fato relevante divulgada quando da alienação do controle, sem prejuízo do disposto no inciso I do §1º do art. 33, se for o caso.

§2º - O requerimento de registro da OPA de que trata o caput deverá ser apresentado à CVM no prazo máximo de 30 dias, a contar da celebração do instrumento definitivo de alienação das ações representativas do controle, quer a

realização da OPA se constitua em condição suspensiva, quer em condição resolutiva de alienação.

§3º - O registro da OPA pela CVM implica na autorização da alienação do controle, sob a condição de que a oferta pública venha a ser efetivada nos termos aprovados e prazos regulamentares.

§4º - Para os efeitos desta instrução, entende-se por alienação de controle a operação, ou o conjunto de operações, de alienação de valores mobiliários com direito a voto, ou neles conversíveis, ou de cessão onerosa de direitos de subscrição desses valores mobiliários, realizada pelo acionista controlador, ou por pessoas integrantes do grupo de controle, pelas quais um terceiro, ou um conjunto de terceiros, representando o mesmo interesse, adquira o poder de controle da companhia, com o definido no art. 116 da Lei nº 6.404/76.

§5º - Sem prejuízo da definição constante do parágrafo anterior, a CVM poderá impor a realização de OPA por alienação de controle sempre que verificar ter ocorrido a alienação onerosa de companhia aberta. (grifo nosso).

14. Voltando ao caso concreto, há provas robustas nos autos no sentido de que Pedro Demenato assumiu o controle da Marambaia Energia no dia 19.10.2009¹⁵ ao adquirir, da Marambaia Investimentos, 4.108.562 ações ordinárias de emissão da Companhia, tendo havido, por meio dessa transação, a transferência do controle da Marambaia Energia¹⁶.

15. A prova cabal da operação é o formulário de Transferência de Ações, Cotas e/ou Debêntures Escriturais/Nominativas (fls. 44-45), datado de 19.10.2009, assinado por representantes da Marambaia Investimentos e por Pedro Demenato, que atesta a transferência de 4.108.562 ações ordinárias de emissão da Marambaia Energia ao Acusado, por meio de transação onerosa no valor total de R\$4.108.562,00 (preço unitário de R\$1,00).

16. Além disso, Pedro Demenato consta no Formulário de Referência de 2010 como controlador da Marambaia Energia, com participação de 50,41% do capital social, fato reconhecido pela própria Companhia, em resposta aos questionamentos feitos pela CVM.

17. A posição do Acusado como controlador da Companhia é corroborada, ainda, pelo conteúdo da lista nominativa dos acionistas da Marambaia Energia (data-base 07.03.2012)¹⁷, enviada pelo Itaú Unibanco S.A. à CVM, em que consta o Acusado como detentor de 6.544.116 ações de um total de 12.981.001, com participação, portanto, equivalente a 50,41% do capital social da Marambaia Energia.

18. É importante ressaltar que, de acordo com a referida lista, Pedro Demenato aparece, de maneira isolada, com participação elevada na Companhia, uma vez que o segundo maior acionista detém ações representativas de menos de 5% do capital social, conforme pode ser observado na tabela abaixo:

	Quantidade de Ações	% do capital social
<i>Acionista 1</i>	610.000	4,699%
<i>Acionista 2</i>	272.000	2,095%
<i>Acionista 3</i>	223.700	1,723%
<i>Acionista 4</i>	212.900	1,640%
<i>Acionista 5</i>	200.000	1,541%

Tabela A: cinco maiores participações minoritárias (49,59% distribuídos por aproximadamente 660 acionistas)

19. Levando em conta todas as provas presentes nos autos, os fatos apurados são considerados incontroversos, tendo sido configurada, portanto, infração ao disposto nos artigos 254-A da Lei nº 6.404/76 e 29 da Instrução CVM nº 361/02.

20. Quanto à autoria, não há dúvidas de que a obrigação estipulada nos referidos artigos é dirigida ao adquirente do controle e, portanto, a responsabilidade pela infração apontada deve recair sobre Pedro Demenato.

21. Há de se destacar, por fim, a importância, para assegurar o funcionamento eficiente e regular do mercado e a devida proteção aos minoritários, da regra aqui analisada e do seu efetivo cumprimento, cuja violação é considerada infração grave nos termos do art. 41 da Instrução CVM nº 361/02. O descumprimento da obrigação de realizar oferta pública de aquisição das ações dos minoritários votantes é, de fato, muito grave, pois, além de ter o potencial de causar prejuízos financeiros, mina a confiança dos investidores e diminui a sua disposição para investir no mercado de capitais.

22. Eventuais prejuízos podem (e devem) ser discutidos no âmbito do judiciário, instância competente para dirimir questões indenizatórias, mas, cabe a esta Autarquia, visando a atingir as finalidades que lhe foram conferidas nos termos do art. 4º da Lei nº 6.385/76, reprimir esse tipo de conduta e punir os seus responsáveis.

23. Dessa forma, em face de todo o exposto e levando em consideração os antecedentes do Acusado¹⁸, com fundamento no art. 11, da Lei nº 6.385/76, voto pela condenação de Pedro Demenato Fernandes à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$400.000,00, por infração ao disposto nos artigos 254-A, da Lei nº 6.404/76, e 29, da Instrução CVM nº 361/02, sendo esta última considerada grave nos termos do art. 41 da Instrução CVM nº 361/02.

Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2017.

Henrique Balduino Machado Moreira
Diretor-Relator.

¹ Art. 254-A – A alienação, direta ou indireta, do controle de companhia aberta, somente poderá ser contratada sob a condição, suspensiva ou resolutiva, de que o adquirente se obrigue a fazer oferta pública de aquisição das ações com direito a voto de propriedade dos demais acionistas da companhia, de modo a lhes assegurar o preço no mínimo igual a 80% (oitenta por cento) do valor pago por ação com direito a voto, integrante do bloco de controle.

² Art. 29 – A OPA por alienação do controle de companhia aberta será obrigatória, na forma do art. 254-A da Lei 6.404/76, sempre que houver alienação, de forma direta ou indireta, do controle de companhia aberta, e terá por objeto todas as ações de emissão da companhia às quais seja atribuído o pleno e permanente direito de voto, por disposição legal ou estatutária.

³ Conforme consta nas Informações Anuais (IAN) de junho de 2009 (fls. 25-26)

⁴ A assembleia geral extraordinária em questão foi realizada em 12.12.2007 (fls.70).

⁵ A Acusação afirma que L.C.F. seria controlador da Marambaia Capital e da Marambaia Investimentos (item 8 do termo de acusação).

⁶ Fls. 89-90.

⁷ Redação original do art. 254, caput, e §1º, da Lei nº 6.404/76, revogados pela Lei nº 9.457/97.

⁸ Conforme consta na “justificação” do Projeto de Lei nº 1.564, de 1996 (Projeto Kandir), que, posteriormente, se transformou na Lei nº 9.457/97, integrante do processo de tramitação do projeto, disponível em http://WWW.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?jsessionid=2EC8BDA89E5B530142B408E8143A6C06.proposicoesWeb?codteor=1135039&filename=Dossie+-PL+1564/1996.

⁹ EIZIRIK, Nelson; Gaal, Ariádna B.; Parente, Flávia; Henriques, Marcus de Freitas. Mercado de capitais – regime jurídico, 3ª ed. rev. e amp. Rio de Janeiro, Renovar, 2011, pág. 607. ANDREZO, Andrea Fernandes. Alienação de Controle de Companhia Aberta e a Recente Reforma da Legislação Societária. Revista de Direito Mercantil, São Paulo, vol. 130, abr./jun.2003, pág.164. PENNA, Paulo Eduardo. Alienação de controle de companhia aberta. São Paulo, *Quartier Latin*, 2012, páginas 25-26.

¹⁰ Há estudos no sentido de que quanto maior a proteção aos investidores, maior a disposição desses em financiar as companhias, por que haveria menor risco de expropriação por parte de administradores e controladores. As companhias, por sua vez, teriam mais incentivos para emitir valores mobiliários quando os investidores estão dispostos a pagar mais por eles (in ANDREZO, Andrea Fernandes. Op. Cit., páginas 160-161).

¹¹ PENNA, Paulo Eduardo. Alienação de controle de companhia aberta. São Paulo, *Quartier Latin*, 2012, pág. 38.

¹² PENNA, Paulo Eduardo, Op. Cit., pág. 47.

¹³ Uma das razões para a existência desse *spread* seria a insuficiente proteção dos interesses dos minoritários, que resultaria na apropriação, pelos controladores, dos chamados *private benefits of control* (i.e., acesso a empréstimos subsidiados, uso de bens da sociedade para fins particulares etc.); ou seja, se aceita pagar um sobrepreço pelo controle de certas companhias em razão da expectativa de que esse valor será recuperado por meio dessa expropriação (in EIZIRIK, Nelson, Mercado de Capitais – Regime Jurídico – 3ª edição, Renovar, p.608).

¹⁴ Trecho extraído do voto do diretor-relator Pedro Oliva Marcilio de Sousa, proferido no âmbito do PAS CVM nº RJ2005/4069, o qual foi acompanhado pelos demais membros do Colegiado.

¹⁵ Com relação à dispersão acionária da Companhia à época dos fatos, ressalta-se que, por meio de comunicado ao mercado, datado de 06.08.2009, a Companhia, ao responder questionamentos feitos pela BM&FBOVESPA, informou que a posição acionária da Marambaia Energia na mencionada data era a seguintes: "Marambaia Investimentos e Participações Ltda. e demais membros do grupo de controle – 50,4%; Metynis Participações S.A. – 44,7%; Outros – 4,9%".

¹⁶ Conforme "Termo de Transferência de Ações, Cotas e/ou Debêntures Escriturais/Nominativas", enviado pelo Banco Itaú S.A., às fls. 45-46.

¹⁷ A referida lista foi encaminhada pelo Itaú em 22.01.2013, em resposta ao OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-4/nº13/13 (fls. 7-23).

¹⁸ Foram instaurados dois processos administrativos sancionadores pela CVM para verificar a conduta do Acusado: (i) RJ2012/3787, em que Pedro Demenato foi condenado à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$200.000,00, tendo sido responsabilizado pela não divulgação de fato relevante, em infração ao disposto no art. 6º, parágrafo único, da Instrução CVM nº 358/02; e (ii) RJ2011/7384, instaurado pela SEP com o objetivo de analisar a responsabilidade do Acusado, na qualidade de Diretor de Relações com Investidores da Marambaia Energia, pela não prestação, nos prazos devidos, de informações obrigatórias previstas na Instrução CVM nº 480/09, tendo sido celebrado Termo de Compromisso, aprovado pelo Colegiado da CVM em reunião realizada em 19.10.2011.